

1517463-12.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... de sua inaplicabilidade nos casos de tráfico, ainda que pequena a quantidade de drogas. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO - SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE - PEQUENA QUANTIDADE - INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517463-12.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517463-12.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2209925/2019 - 01º D.P. SE, 6394063 - 01º D.P. SE, 3408/19/101 - 01º D.P. SE,

2209925 - 01º D.P. SE, 3408/19/101 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLÁUDIO GABRIEL DE PAIVA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

CLÁUDIO GABRIEL DE PAIVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19 de julho de 2019, por volta das 17h20, na Praça da Sé, São Paulo - SP, trazia, para fins de tráfico, 01 invólucro de cocaína, pesando 0,3g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em 09 de agosto de 2019 houve a determinação para a notificação do réu e

apresentação da defesa prévia (fls. 40).

Após não ser localizado (fls. 58, 99, 106, 110, 113 e 119), foi notificado por edital (fls. 130). Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, a DPE apresentou sua defesa prévia (fls. 138/139), arrolando as mesmas testemunhas da acusação. A denúncia foi recebida (fls. 141) e o réu citado por edital (fls. 148).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou constituição de patrono nos autos, o feito foi suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP, em 27 de novembro de 2020 (fls. 158). Posteriormente, sobreveio a informação de que o réu estaria preso por outro feito (fls. 178/182), vindo a ser notificado presencialmente em 17 de março de 2022 (fls. 192). Por fim, foi citado pessoalmente (fls. 239).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º. Da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime inicial aberto.

O Defensor requereu a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade material decorrente da ausência de lesividade (insignificância). Subsidiariamente, argumentou quanto à desclassificação para o delito do artigo 33, § 2º, da Lei de Drogas. Em caso de condenação por tráfico, acompanhou a manifestação ministerial quanto à pena.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é totalmente procedente.

Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais, porquanto o artigo 301 do Código Penal é claro ao dispor que qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante delito. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do C. STJ:

"(...) I - É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). II - O v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. De fato, afere-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protraí-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (precedentes). III - In casu, os guardas civis, durante patrulhamento de rotina, avistaram o ora agravante em local já conhecido como ponto utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e, por ter o acusado apresentado nervosismo ao deparar-se com a viatura, decidiram os agentes por abordá-lo, momento em que localizaram em sua posse 15 (quinze) porções de maconha (fls. 204-205). Indagado a respeito de todo o contexto, o então suspeito admitiu que estava realizando o comércio espúrio, bem como que detinha entorpecentes em sua residência para fins de comercialização (fl. 205), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. (...) Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 678.534/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021).

Ato contínuo, a despeito da argumentação pela ausência de lesividade, é certo que se tratava de porção de cocaína, droga de relevante efeito psicotrópico ao usuário, sendo que a despeito da pequena quantidade (01 porção - peso de 0,3g), é certo que

há lesividade suficiente à saúde pública, porquanto no contexto dos autos foi visto comercializando tal porção, prática que evidencia o tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e enseja maior reprovabilidade em sua conduta, eis que não se trata de porte para consumo próprio ou mesmo induzimento ao uso de droga ou mesmo oferecimento eventual, haja vista que se encontrava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, houve comercialização, tanto que recebeu um pagamento pela porção, bem como não há qualquer indicio de que Eufrásio fosse pessoa de seu relacionamento ou que se destinasse para uso conjunto.

Ademais, a alegação da ausência de lesividade entra no contexto de atipicidade material decorrente do princípio da insignificância, sendo que o C. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de sua inaplicabilidade nos casos de tráfico, ainda que pequena a quantidade de drogas. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PEQUENA QUANTIDADE – INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância.” (HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019).

Em relação aos depoimentos, os guardas civis metropolitanos narraram que estavam em patrulhamento de rotina perto do marco zero da Praça da Sé, quando avistaram o réu recebendo certo valor em dinheiro de um indivíduo e passando para ele um objeto, que parecia ser uma porção de droga. Decidiram proceder à abordagem e quando se aproximaram os dois saíram caminhando rapidamente em sentidos opostos. João participou da abordagem da testemunha Eufrásio. Disse que quando estava para ser abordado, tal indivíduo dispensou uma porção de cocaína ao chão, a qual foi recuperada. Ele negou que estivesse em poder da droga. O guarda Luis participou da abordagem do réu. Em revista pessoal a ele foi encontrada uma porção de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Disse que a embalagem da droga encontrada com o réu era igual à embalagem da droga encontrada com o outro indivíduo. João disse que o réu teria confessado a traficância, enquanto Luis disse que ele negou. João disse que o outro indivíduo negou que tivesse comprado droga, enquanto Luis disse que ele confirmou que havia comprado a droga, mas isentou o réu. Não conheciam o réu ou o outro indivíduo anteriormente. João não lembrava se o réu e o outro indivíduo pareciam ser moradores de área livre. Já Luis disse que os dois declararam serem moradores de área livre. O réu não parecia estar sob efeito de drogas e com ele não havia qualquer petrecho para consumo de drogas. Ninguém interveio em favor deles. Houve um certo tumulto causado por moradores de área livre no local, como costuma ocorrer em ocorrências similares.

O réu, em seu interrogatório, declarou que na época era morador de área livre na Praça da Sé, onde costumava fazer venda de balas, como ocorria no dia dos fatos. Havia passado a noite usando drogas com diversas pessoas, dentre elas a testemunha Eufrásio. Estava vendendo balas quando Eufrásio aproximou-se e pediu uma porção de cocaína. Como tinha droga consigo, entregou uma porção a ele, que disse que lhe pagaria posteriormente. Foi abordado em seguida, sendo que tinha consigo uma caixa de balas. O dinheiro era proveniente da venda de balas. Conhecia os guardas civis metropolitanos apenas de vista. É usuário de cocaína e maconha.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade e forma de acondicionamento, sendo que o réu tinha em seu poder duas porções, uma que foi apreendida com ele e outra que foi entregue a Eufrásio; visualização pelos guardas civis metropolitanos de movimento de troca entre o réu e Eufrásio, sendo que ambos os guardas afirmaram que viram quando este entregou àquele certa quantia em dinheiro, recebendo, em seguida, um objeto que lhes pareceu ser uma porção de droga; as porções de drogas encontradas com o réu e com Eufrásio tinham a mesma embalagem; a ausência de demonstração que a droga destinava-se para seu consumo próprio, sendo relevante que na fase policial o réu não se declarou como morador de área livre, tendo declinado endereço muito distante do local dos fatos; ausência de localização de qualquer petrecho para consumo de drogas com o réu, que, segundo os guardas, sequer parecia

estar sob efeito de drogas. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câm. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os guardas ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

Observo que as pequenas contradições sobre aspectos não fundamentais havidas em seus depoimentos apenas denotam que prestaram declarações verdadeiras, sem que tenha havido prévio ajuste, sendo certo que as contradições havidas dizem respeito a pontos marginais e não essenciais à diligência.

No mais, a versão apresentada pelo réu restou isolada, inexistindo qualquer aspecto a comprovar seu enredo, que sequer se mostra verossímil e apto a infirmar a prática do tráfico de drogas relatada pelos policiais. Eufrasio não foi ouvido em Juízo e na fase policial silenciou. Não há apreensão de qualquer caixa de balas a comprovar a versão do acusado.

Desta feita, inviável a desclassificação pretendida pela defesa.

A substância entorpecente apreendida foi submetida a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 43/45), também a corroborar o contido na denúncia.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima mencionados. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, ausentes condições desfavoráveis, motivo pela qual as penas permanecem no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, as penas permanecem no mínimo legal, porquanto presente a atenuante da menoridade relativa, sendo inviável eventual redução aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, as penas devem ser reduzidas em 2/3, em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, como ocorre no presente caso, tornando-se definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante a primariedade do réu e a quantidade de pena, fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento.

Por seu turno, em que pese se trate de réu primário, é certo que não faz jus ao benefício do acordo de não persecução penal, haja vista que, muito embora seja primário, responde por outros delitos (fls. 232/233), indicando conduta criminal reiterada, restando inviável o benefício, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu CLÁUDIO GABRIEL DE PAIVA SANTOS, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

A despeito de o entendimento pessoal desta magistrada ser no sentido da total incompatibilidade entre o delito de tráfico e a substituição por pena restritiva de direito, após reiteradas reformas às sentenças proferidas pelas instâncias superiores, curvo-me ao entendimento do E. STJ no sentido de não haver impossibilidade de se conceder tal benefício ao pequeno traficante, beneficiado com a causa de diminuição de pena. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções (não podendo ser entidade educacional ou de saúde), bem como por prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 141. Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

P.R.I.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA